

1508272-26.2022.8.26.0037

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sergio Augusto de Freitas Jorge

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... se ele tinha envolvimento com o narcotráfico, pois o conhecia apenas de vista. Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e na época do ocorrido trabalhava com seu pai fazendo bicos como pintor.

Ocorre, porém, que, apesar da versão exculpatória exarada pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o acervo probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

2ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses nº 1998

CEP: 14801-425 - Araraquara - SP

Telefone: (16) 3336-1034 - E-mail: araraq2cr@tjsp.jus.br

1508272-26.2022.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508272-26.2022.8.26.0037

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DO AMARAL ROSARIO

Juiz de Direito: Dr. Sergio Augusto de Freitas Jorge

Vistos.

JÚLIO CÉSAR DO AMARAL ROSÁRIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c.c. o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 16:10 horas, na Avenida José dos Santos Seves, nº 1058, Vale Verde, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 3,0 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo em sua conduta o adolescente Guilherme Henrique Menigosi (com 16 anos de idade), com ele praticando o crime de

tráfico de drogas.

Notificado o acusado (fl. 176) e apresentada defesa preliminar (fls. 177/184), a denúncia foi recebida (fls. 186/187). O réu foi citado (fl. 266).

Na fase de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Acusação, sendo o réu interrogado ao final (fls. 274/275).

Em debates orais, a DD. Representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 274/275), ao passo que, em memoriais, o Nobre Defensor postulou a sua absolvição ou, em caso contrário, o afastamento das majorantes contidas na denúncia, com a fixação da pena no mínimo legal, em regime prisional inicial semiaberto (fls. 276/291).

É o relatório.

DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida sobretudo pelo teor do auto de exibição e apreensão (fl. 26) e dos laudos de constatação provisória (fls. 28/30) e definitiva de entorpecentes (fls. 109/111), com resultados positivos para cocaína.

Por seu turno, a autoria do delito foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes coligidos na fase inquisitiva.

Tanto em sede policial (fl. 06) como em juízo (cf. gravação audiovisual de fls. 274/275), o acusado negou a imputação. Aduziu que, na data mencionada, passava pelo local dos fatos quando parou apenas para pedir informações ao adolescente Guilherme a respeito de Otávio, amigo em comum de ambos, momento em que foram abordados por policiais militares. Não trazia consigo nada de ilícito nem tampouco imaginava que o menor estivesse vendendo "essas coisas". Esclareceu que, ao se aproximar para conversar com Guilherme, um automóvel ali encostou, mas não viu se o adolescente chegou a entregar algo para o condutor do veículo, pois não prestou atenção nisso. Em poder do menor foram localizadas porções de droga e certa quantia em dinheiro. Negou que estivesse em companhia de Guilherme, bem como não soube informar se ele tinha envolvimento com o narcotráfico, pois o conhecia apenas de vista. Negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e na época do ocorrido trabalhava com seu pai fazendo bicos como pintor.

Ocorre, porém, que, apesar da versão exculpatória exarada pelo réu nas ocasiões em que ouvido, o acervo probatório coligido durante a persecutio criminis contém elementos seguros e aptos a demonstrar a sua responsabilidade, na espécie.

Assim é que os policiais militares Gouvêa Júnior e Soler relataram que, na data mencionada, durante patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pela constante prática do narcotráfico, visualizaram o acusado juntamente com o adolescente Guilherme fazendo contato com o condutor de um veículo VW/Voyage. Ao avistarem a aproximação da viatura policial, eles passaram a caminhar em direções opostas e o veículo deixou o local em alta velocidade, o que lhes despertou suspeita. Efetuaram a abordagem de ambos e, em busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o réu. Em poder do menor foram encontrados 10 microtubos de cor verde contendo cocaína, além da quantia em dinheiro de R\$ 30,00 em notas trocadas. Indagado, o acusado negou a prática do tráfico de drogas e disse que apenas passava pelo local. Já o adolescente admitiu a comercialização do entorpecente e confirmou que o numerário era oriundo das vendas, revelando que antes da abordagem vendera 3 microtubos de cocaína ao condutor do mencionado veículo, pelo valor unitário de R\$ 10,00. Ele

ainda afirmou que o restante da droga apreendida era para o seu próprio consumo. No momento da abordagem estavam no local apenas o acusado e o adolescente, que reside a uns 10 ou 15 metros do local. Esclareceram que naquele mesmo dia e local, após o presente fato, efetuaram outras prisões pela mesma prática ilícita (cf. gravação audiovisual de fls. 274/275).

Soler ainda acresceu já ter abordado o adolescente anteriormente pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do réu. Os elementos de convicção produzidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

Na hipótese em exame, a conclusão de que a droga apreendida se destinava ao comércio ilícito e ao fornecimento a terceiros é obtida não apenas pela palavra do adolescente em solo policial (fl.05), mas sobretudo pela natureza e forma de acondicionamento do tóxico (10 microtubos do tipo eppendorf de cor verde contendo cocaína, com peso líquido total de 3,0 gramas, já prontos para a venda e entrega a terceiros - cf. auto de fl. 26, fotografia de fl. 38 e laudos de fls. 28/30 e 109/111).

Frise-se que, apesar do reduzido peso líquido do entorpecente apreendido, sua divisão em várias porções individuais indicava grande potencial de disseminação entre diversos usuários compradores da droga.

Cumpram-se ainda destacar que houve a apreensão, no mesmo cenário fático, em poder do adolescente infrator, de quantia em dinheiro em notas trocadas (R\$ 30,00), confessadamente oriunda da prática ilícita em questão (cf. auto de fl. 26 e guia de fl. 108).

Ora, não se afigura crível a alegação do réu de que na data dos fatos apenas passava pelo local quando parou para pedir informações ao menor Guilherme a respeito do suposto amigo em comum Otávio, sendo então abordado e detido pelos milicianos.

Isso porque, no momento dos fatos, o imputado foi visualizado pelos castrenses em companhia do adolescente mantendo contato com o condutor de um veículo parado na via - provável usuário comprador da droga -, tendo todos se evadido do local ao notarem a aproximação da viatura policial.

Ressalte-se, nesse ponto, que o menor infrator admitiu, tanto aos milicianos como à autoridade policial, que de fato promovia o comércio de drogas no local dos fatos e inclusive efetuara a venda de 3 microtubos da droga ao mencionado condutor do veículo (tendo consigo os R\$ 30,00 correspondentes à venda pelo valor unitário de R\$ 10,00), permitindo inferir-se que ele e o réu agiam de comum acordo e com identidade de propósitos no exercício da atividade criminosa.

Os elementos de convicção coligidos aos autos igualmente permitem concluir que o acusado se aproveitava da inimputabilidade do adolescente Guilherme para manter com este o entorpecente destinado à venda.

Além disso, no meio policial já havia informações dando conta da frequente prática do tráfico de drogas no local dos fatos e nas suas imediações, consoante se infere do teor dos depoimentos dos policiais ouvidos em solo judicial e do documento de fl. 115, que aponta a existência de registro alusivo a tal prática ilícita em área próxima, contendo expressa menção ao nome do réu.

Tais aspectos, examinados de forma conjunta, afastam a veracidade da frágil versão

exculpatória exarada pelo imputado e confirmam a ocorrência, na espécie, da guarda e do transporte da droga para fins da mercancia maldita.

Sabe-se, outrossim, que, para a configuração do delito de narcotráfico, não se exige qualquer ato de efetiva entrega de droga, bastando que os agentes transportem, tragam consigo, guardem ou mantenham em depósito a substância entorpecente, sendo inexigível a traditio para fins de consumação do crime (RJTJSP 97/512).

Desse modo, todas as circunstâncias do fato acima mencionadas indicam de modo claro e estreme de dúvidas que o entorpecente apreendido era pertencente ao réu - reincidente na mesma prática ilícita (cf. certidão de fls. 49/52) - e a seu comparsa juvenil e se destinava, efetivamente, à ilícita revenda e ao fornecimento a terceiros, ainda que de forma gratuita, não sendo unicamente para o uso próprio de ambos, até porque o imputado declarou em juízo não fazer uso de drogas.

E, ainda que assim não fosse, é consabido que a mera condição de usuário de tais substâncias não exclui, por si só, a prática do narcotráfico, pois é fato comum o usuário dedicar-se ao comércio nefasto ou à simples "guarda temporária" da droga para terceiro a fim de assim quitar suas dívidas com outros traficantes ou mesmo amealhar recursos para poder sustentar o próprio consumo pessoal.

Convém ainda registrar, a reforçar a maior reprovabilidade da conduta ilícita do réu, que sua ação envolveu diretamente o adolescente Guilherme Henrique Menigosi, com 16 anos de idade ao tempo dos fatos (cf. auto de qualificação de fl. 21 e cópia do RG de fl. 36), o qual também foi surpreendido em atitude ilícita, como visto, na data e no local dos fatos, a atrair a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Verifica-se, a propósito, que ao referido menor, por sua atuação no mesmo fato objeto da presente ação penal, já foi aplicada, em decisão proferida em procedimento de apuração de ato infracional, a medida socioeducativa de internação em unidade da Fundação CASA, consoante se infere de pesquisa realizada no sistema informatizado do E. TJSP (Proc. nº 1508277-48.2022.8.26.0037, da d. Vara da Infância e da Juventude local, atualmente em grau de recurso).

Despreza-se, ainda, por sua evidente mendacidade, a palavra do menor na fase policial, quando tentou assumir sozinho a propriedade do entorpecente e a dedicação à venda no local dos fatos.

No entanto, é de se afastar, no caso em exame, a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei nº 11.343/06 - cometimento da infração nas imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares e outros locais assemelhados -, uma vez que os locais mencionados na denúncia (Escola Municipal CAIC Prefeito Rubens Cruz, Igreja Presbiteriana Nova Canaã e UPA Nefália de Oliveira Lauer) se situam a, respectivamente, 575 metros, 550 metros e 320 metros de distância do local dos fatos (cf. laudo pericial de fls. 166/168).

Cabe assentar, nesse aspecto, que a expressão "imediações" encerra conceito jurídico relativamente indeterminado, cujo preenchimento o Juiz deve efetuar tendo em vista as circunstâncias do caso concreto e sempre à luz da finalidade do dispositivo, que é proteger tais locais contra as investidas do tráfico. Assim, não há uma medida aritmética. Incide a majorante se o agente pode alcançar, com facilidade e em pouco tempo, os locais especialmente protegidos, o que à evidência não ocorre no presente caso, dadas as expressivas distâncias (equivalentes a vários quarteirões).

Confira-se a lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi:

"O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida aritmética rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável, em função do perigo maior que a lei procura coibir; as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem" (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006, Ed. Saraiva, 2007, p. 135).

Releva consignar, outrossim, especificamente no que concerne ao segundo local mencionado, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou recentemente o entendimento de que o tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas não foi contemplado pelo legislador no rol das majorantes previstas no referido dispositivo, não podendo, portanto, ser utilizado com esse fim, tendo em vista que no Direito Penal incriminador não se admite a analogia in malam partem (Habeas Corpus nº 528.851/SP - 6ª Turma - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 05.05.2020).

Com efeito, caso o legislador quisesse punir de forma mais gravosa também o fato de o agente cometer o delito nas dependências ou nas imediações de igreja, teria previsto isso expressamente, assim como fez em relação aos demais locais especialmente protegidos.

Demonstradas, portanto, a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, passo à dosimetria das penas a lhe serem aplicadas.

Ante a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, e sobretudo levando-se em conta a intensa culpabilidade do réu, representada pela maior reprovabilidade de sua conduta, praticada ainda durante o gozo de livramento condicional (cf. certidão de fls. 49/52, especialmente a anotação contida à fl. 50) - vale dizer, antes mesmo de concluído o processo de reintegração ao convívio social buscado pela pena anteriormente imposta -, fixo as penas-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) - caracterizada pela anterior condenação definitiva que o acusado ostenta pela prática da mesma espécie de delito, retratada na certidão de fls. 49/52 -, elevo as penas em 1/6 (um sexto), alcançando 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na derradeira etapa do procedimento trifásico, presente a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente na prática do tráfico de drogas), elevo as penas em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no piso mínimo.

Por fim, não há cogitar-se da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (privilégio), pois o réu não ostenta a necessária primariedade, já que, como visto, é reincidente específico.

Torno as reprimendas, pois, definitivas, diante da ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Outrossim, não obstante tenha o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 111.840/ES (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012), declarado incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), por entender que a norma contraria a CF/88, especificamente no que diz respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI), para admitir a imposição, aos condenados

por crimes hediondos e a eles equiparados, de regime prisional inicial diverso do fechado, o fato é que, na espécie, considerando o quantum da pena corporal, bem como a reincidência específica do réu, a nocividade de sua conduta e a acentuada periculosidade por ele demonstrada por ocasião da prática delitiva, a pena carcerária ora imposta será cumprida inicialmente em regime prisional fechado, até porque se revela o único cabível na hipótese, diante do que prevê o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por fim, no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, o Excelso Pretório, nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS (Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2010), declarou inconstitucional dispositivo da lei que vedava essa conversão (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06).

E o Senado Federal, em observância à decisão do Colendo STF, por força da Resolução nº 05/2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" contida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Todavia, a referida substituição de penas revela-se incabível, no caso em exame, tendo em vista a reincidência específica do acusado e o próprio montante da pena corporal aplicada (superior a 4 anos de reclusão), que não se amoldam ao disposto no art. 44, inciso I, e § 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu JÚLIO CÉSAR DO AMARAL ROSÁRIO à pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Não poderá o acusado recorrer em liberdade, eis que subsistem íntegros os motivos que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar durante toda a persecutio criminis.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de decretar o perdimento do numerário apreendido, eis que tal providência já foi determinada pelo Juízo da Infância e da Juventude local no âmbito do procedimento instaurado em face do adolescente infrator.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Araraquara, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA